

第2節 有罪判決

刑事訴訟法
No297

共通問題 H25-36

(配点: 3)

月 日

月 日

量刑において起訴されていない犯罪事実、すなわち余罪をどう扱うべきかに関し、「量刑は、被告人の性格、経歴及び犯罪の動機、目的、方法等全ての事情を考慮して、裁判所が処断刑の範囲内において、適当に決定すべきものであるから、その量刑のための一情状として、いわゆる余罪をも考慮することは、必ずしも禁じられるところではない。」との見解がある。次のアからオまでの各記述のうち、この見解に対する批判になり得ないものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア. 起訴された犯罪事実のほかに、起訴されていない犯罪事実を余罪として認定し、実質上これを処罰する趣旨で量刑資料として考慮し、被告人を重く処罰することとの区別が実際には困難な場合がある。

イ. 余罪が考慮できないと、犯罪に至らない不当な行状などが情状事実に含まれることと均衡を失する。

ウ. 余罪は被告人が犯した別の犯罪事実であるから、情状事実である犯罪傾向の有力な間接事実となる。

エ. 刑事裁判手続において犯罪事実の認定手続と量刑手続とは区分されていないため、量刑資料である余罪が犯罪事実の認定に不当な影響を及ぼすおそれがある。

オ. 余罪も犯罪事実であるため、その認定に当たっては、起訴された犯罪事実に準じた手続保障を求めるべきであるが、量刑のための一情状だとすると厳格な証明を要しないことになる。

1. ア ウ 2. ア オ 3. イ ウ 4. イ エ 5. エ オ

ア 批判となり得る

起訴されていない犯罪事実をいわゆる余罪として認定し、これを実質上処罰する趣旨の下に重い刑を科すことは、憲法31条、38条3項に違反する（最大判昭41.7.13等）。そして本問見解は、認められる量刑のための一情状として余罪を考慮することと、認められない余罪を認定し実質上余罪を処罰する趣旨の下に重い刑を科すこととの区別が可能であることが前提となる。本記述は、その区別が実際には困難な場合があるとするから、本問見解の批判となり得る。したがって、本記述は、本問見解の批判となり得る。

イ 批判となり得ない

本記述は、「余罪を考慮できない」とあることから、余罪を考慮することを認めない見解に対する批判であることがわかる。本問見解は、余罪を考慮することを認める見解である。したがって、本記述は、本問見解の批判となり得ない。

ウ 批判となり得ない

刑事裁判における量刑は、被告人の性格、経歴及び犯罪の動機、目的、方法等すべての事情を考慮して、裁判所が処断刑の範囲内において、適当に決定すべきものである。そして、余罪が情状事実である犯罪傾向の有力な間接事実となるとすると、裁判所が適当な量刑を決定するためには、余罪を量刑のための一情状として考慮すべきと考えることができる。したがって、本記述は、本問見解の批判となり得ない。

エ 批判となり得る

本記述は、刑事裁判手続において犯罪事実の認定手続と量刑手続とは区別されていないことを理由に、余罪を考慮することは量刑資料であっても、犯罪事実の認定に不当な影響を及ぼすおそれがあると批判するものである。よって、本記述は、余罪を量刑のための一情状として考慮することを認める本問見解の批判となり得る。したがって、本記述は、本問見解の批判となり得る。

オ 批判となり得る

本記述は、余罪の認定については起訴された犯罪事実に準じた手続保障を求めるべきであるとの前提に立った上で、余罪を量刑のための一情状だとすると、厳格な証明を要しないことになるとして、余罪を量刑のための一情状として考慮する見解を批判したものである。したがって、余罪を量刑のための一情状として考慮することを認める本問見解の批判となり得る。

以上により、この見解に対する批判になり得ない記述はイとウであり、正解は肢3となる。